

1504594-96.2021.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... CAPS; que foi condenada duas vezes por tráfico; que estava em regime aberto; que mantinha namoro com Aryel; que fazia por volta de um ano que namorava com Aryel; que conheceu Aryel numa festa; que Aryel estava morando com a interrogada fazia três meses; que Aryel já teve envolvimento com o tráfico; que não são verdadeira as acusações; que, no dia, trabalhou e chegou em casa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504594-96.2021.8.26.0664 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504594-96.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2314784/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 21473476 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2939/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2314784 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2939/21/711 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARYEL RODRIGUES DE MARES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de IVANI NASCIMENTO DOS SANTOS e de ARYEL RODRIGUES DE MARES pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da mesma legislação.

Emerge da denúncia (fls. 168/170):

1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data anterior ao dia 18 de novembro de 2021, em horário incerto, na Rua das Paineiras, altura do nº 4.666, Bairro Paineiras, nesta cidade e comarca, IVANI NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificada

a fls. 11/13 e 15, fotografada a fls. 56/58, e ARYEL RODRIGUES DE MARES, qualificado a fls. 21/23 e 25, fotografado a fls. 59/63, em tempos de pandemia, agindo em concurso e com unidade de propósitos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

2. Consta, ainda, que, no dia 18 de novembro de 2021, por volta de 16h, na Rua das Paineiras, nº 4.666, Bairro Paineiras, nas imediações da "Escola Professora Clary Brandão Bertoncini", e do "Complexo Esportivo Vitor Hugo", nesta cidade e comarca, IVANI NASCIMENTO DOS SANTOS e ARYEL RODRIGUES DE MARES, já qualificados, em tempos de pandemia, agindo em concurso e com unidade de propósitos, traziam com eles, mantinham sob sua guarda e guardavam três pinos de cocaína, uma porção de maconha, 23 porções de cocaína, três porções grandes de crack, 14 porções pequenas de crack e mais duas porções de cocaína, tudo para fins de tráfico, conforme auto de contatação provisória (fls.64/66), fotografias (fls. 37/40) e laudo de exame toxicológico (fls. 154/156).

Os denunciados foram notificados (fls. 228 e 233) e apresentaram defesas prévias (fls. 234/45 e 278/302).

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 309/11), designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 309/11).

Os réus foram citados (fls. 400 e 410).

Durante a instrução, colheu-se o depoimento de quatro testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão manifestada na denúncia, a fim de se condenar os denunciados como incurso nos tipos penais mencionados na inicial acusatória.

As Defesas, a seu turno, suscitaram preliminares, postularam a absolvição dos acusados por insuficiência probatória e deduziram teses subsidiárias (fls. 487/535 e 536/545).

É o breve relatório. Decido.

Afasto a preliminar de nulidade dos interrogatórios, uma vez que inexiste direito de um acusado participar do interrogatório de outro acusado no mesmo processo. O artigo 191 do Código de Processo Penal é cristalino: "havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente". Oportuno mencionar o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, eloquente ao escrever que "o interrogatório em separado é a forma correta de se evitar a influência de um corréu sobre o outro, levando-o, muitas vezes, a confissão ou acusação falsa (...) o objetivo maior, entretanto, é evitar que, no mesmo instante em que o corréu está sendo ouvido, o outro absorva a narrativa, influenciando emocional ou psicologicamente pelas declarações, alterando as suas, por conta e risco, podendo representar, para a sua defesa técnica, a pior opção. Por isso, não se tem por meta fazer com que o interrogatório seja uma peça imparcial e genuinamente idônea, porque não faz parte da sua natureza, mas sim que não existam influências momentâneas, prejudiciais à defesa daquele que altera a sua versão, somente porque ouviu o interrogatório precedente do corréu" (Código de Processo Penal Comentado, página 473).

Afasto a preliminar de nulidade de provas decorrentes do ingresso no domicílio do casal. Em infrações permanentes, como no caso de tráfico de drogas, a situação de flagrância se protraí enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). Ademais, o entendimento dominante acerca do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n.

1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). No caso, os policiais tinham denúncias anônimas de que Aryel e Ivani estavam praticando, juntos, o tráfico de drogas na residência do casal. No dia dos fatos, Aryel foi abordado em via pública, na porta de sua residência, em razão de ter visto entregando algo a um motoqueiro. Aryel trazia consigo droga. Ivani, que estava em casa e ia ao socorro do namorado, voltou para dentro da residência. Os policiais, suspeitos de que dentro do imóvel pudesse haver mais drogas, passíveis de ocultação

por Ivani, ingressaram no domicílio. A situação de flagrância, evidente, justifica o ingresso domiciliar sem mandado judicial, tendo sido encontradas mais drogas dentro da casa, precisamente no quarto do casal.

Afasto a preliminar de nulidade da entrevista informal realizada pelos policiais militares no momento do flagrante. Nos termos dos artigos 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e 186 do Código de Processo Penal, o acusado tem direito ao silêncio ou à não autoincriminação, sendo que por ocasião de seu interrogatório, seja ele extrajudicial ou realizado durante a instrução processual, pode se calar acerca dos fatos criminosos que lhe são imputados, ou ainda, e via de consequência do sistema de garantias constitucionais, negar a autoria delitiva, sem que isso enseje apenação criminal ou mesmo valoração negativa dessas declarações pelo togado singular, que poderá, no máximo, desconsiderá-las quando do cotejo com os demais elementos probatórios colacionados. No caso em apreço, a entrevista policial no momento do flagrante não constitui interrogatório extrajudicial. Os acusados, na presença da advogada, foram interrogados pela Autoridade Policial às fls. 9/10 e 19/20, cujos termos fazem referência expressa à garantia do direito ao silêncio. Urge destacar, também, que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo. A propósito: AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; e AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020. Além disso, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na entrevista policial realizada com os acusados no momento do flagrante, no sentido de coagi-los a colaborar com a acusação, assumindo a imputação criminal que lhes foi atribuída. Outrossim, cabe asseverar que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal (HC 586.321/AP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020). Por fim, é certo que os policiais receberam denúncias anônimas de que os acusados estavam praticando tráfico de drogas na residência, o que permite se inferir que eventual irregularidade na entrevista informal, do que não se cogita, não contamina qualquer prova, na medida em que, por fontes independentes, a persecução criminal culminaria na apreensão dos entorpecentes encontrados no domicílio do casal. Não há outras preliminares ou prejudiciais ao mérito. Encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço à análise do mérito.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prevê como crime as seguintes condutas, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa

O bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva de qualquer das condutas previstas no tipo incriminador. Droga, no caso, como elemento normativo do tipo, é toda substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, assim considerada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e listada na Portaria SVS/MS 344, de 12/05/98.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, consubstanciado na vontade e consciência de praticar uma das várias condutas nucleares do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o agente pleno conhecimento de que a droga é entorpecente ou que causa dependência física ou psíquica, e que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, é crime de mera conduta, sendo irrelevante a prova da comercialização.

Por sua vez, eis a redação do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, in verbis:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Passo a analisar os elementos de prova colhidos.

A materialidade do tráfico de drogas restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 29/33), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 34/36), pelas fotografias (fls. 37/41), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 64/66), pelo laudo da perícia de objetos (fls. 195/200), pelo laudo pericial do local (fls. 249/252), pelo laudo pericial em telefone celular (fls. 253/274), pelo laudo definitivo de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada presença das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) no material analisado (fls. 154/156) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual.

As substâncias em questão, aliás, encontram-se presentes na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria é inconteste e recai sobre os acusados.

A testemunha Vladimir Sérgio de Freitas Junior, policial militar, disse, em juízo, que é sargento da Polícia Militar; que estava patrulhamento; que tinha recebido denúncias anônimas de que Aryel e Ivani estavam se dedicando ao trafico de drogas; que, no dia dos fatos, avistou Aryel fazendo contato com motoqueiro; que Aryel parecia entregar algo ao motoqueiro, o qual se evadiu; que Aryel tentou adentrar a residência onde mora com Ivani; que Aryel não conseguiu adentrar à residência; que a abordagem de Aryel foi em via pública, na calçada; que Aryel tinha três porções de cocaína, uma porção de maconha, além de R\$ 40,00, e um aparelho celulares; que Ivani apareceu na porta da residência, juntamente com outra pessoa identificada como Stefani, que era sua nora; que Ivani adentrou rapidamente à casa; que imaginou que pudesse haver mais entorpecentes dentro da casa; que adentrou à residência; que Ivani entrou no quarto da residência; que Ivani foi avistada com um frasco de spray nas mãos; que verificou que o frasco continha um fundo falso; que tinha entorpecente dentro do frasco; que dentro do frasco havia 23 porções de cocaína, sendo 6 pinos e 17 embalagens plásticas; que em cima da cômoda do quarto havia outro frasco idêntico, o qual também continha fundo falso, onde havia mais entorpecente, sendo 17 porções de "crack" e mais 2 porções de cocaína; que também foi localizado mais dois celulares e R\$ 38,00; que, no local onde o segundo frasco foi encontrado, havia um pote de vidro com diversas embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecente; que, na casa, residia Ivani, Aryel e Stefani; que Stefani é esposa de Rodrigo, filho de Ivani; que, dias após, Stefani e Rodrigo foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas; que outras pessoas da vizinhança apareceram no local no momento da abordagem policial; que a casa é próxima de complexo esportivo e de uma escola; que havia crianças utilizando a quadra do completo; que chegou a ver Aryel entregando algo ao motoqueiro; que o motoqueiro se evadiu e não foi possível abordá-lo; que a distância de dez a quinze metros de onde Aryel foi visto com o motoqueiro; que não se recorda se foi encontrada chave com Aryel; que Aryel foi algemado; que não se recorda se o portão do imóvel estava com cadeado; que não se recorda se havia placa de venda de "geladinho" na porta da residência; que as denúncias que pairavam contra os réus eram de dias anteriores; que Ivani estava dentro do quarto quando foi abordada; que informou que Ivani tinha direito ao silêncio; que o quarto era de Ivani e de Aryel; que todo o entorpecente foi encontrado no quarto; que a abordagem de Aryel foi na calçada do imóvel; que adentrou o imóvel apenas após avistar Ivani correndo para dentro da residência.

A testemunha Hebert Coutinho Da Silva, policial militar, disse, em juízo, que é policial militar; que participou da prisão de Aryel e de Ivani; que a equipe policial tinha conhecimento de denúncias de que os réus estavam praticando trafico de drogas; que intensificou patrulhamento; que, na data dos fatos, visualizou Aryel entregando algo a um motoqueiro; que motoqueiro se evadiu; que Aryel tentou correr, mas foi contido; que, com Aruel, havia entorpecente no bolso (pinos de cocaína e

uma porção de maconha) e quantia em dinheiro; que Ivani foi até a entrada da residência, onde Aryel estava sendo abordado e, ao ver os policiais, entrou rapidamente no imóvel; que adentrou à residência; que Ivani foi vista com um frasco de spray nas mãos, que havia fundo falso nesse frasco, dentro do qual tinha cocaína, em pinos e em invólucros; que no quarto do casal também havia outro frasco idêntico contendo drogas; que também havia aparelhos celulares no quarto; que Ivani e Aryel assumiram a propriedade da droga; que tomou conhecimento de que Stefani foi presa posteriormente com seu esposo em razão de tráfico de drogas; que próximo da residência há completo esportivo e uma escola; que foram apreendidas embalagens plásticas para comercialização de drogas; que precisou usar força física para conter Aryel, pois ele resistiu à prisão e tentou adentrar à residência; que havia mais de uma denúncia, de dias anteriores, de que o casal estava se dedicando ao tráfico; que o depoente recebeu denúncia de forma telefônica; que ligaram no telefone pessoal do depoente; que fez patrulhamento em razão das denúncias; que não mantém contato com a DISE; que as denúncias datavam de alguns dias; que a abordagem de Aryel foi do lado externo do imóvel, na calçada; que adentrou à residência apenas após Ivani avistar os policiais e voltar para o interior do imóvel; que a flagrância foi apenas na data dos fatos; que, nos dias anteriores, não puderam constatar traficância; que Stefani, moradora da residência, autorizou o ingresso no imóvel; que ficou próximo de Aryel; que Aryel quis assumir a propriedade da droga para livrar Ivani da acusação; que Ivani disse que a droga seria do casal; que os réus foram orientados acerca de seus direitos, inclusive ao silêncio; que o ocupante da motocicleta que se evadiu; que havia crianças no complexo esportivo; que Ivani foi abordada dentro quarto da residência; que o quarto era dos dois réus; que a droga foi encontrada dentro do quarto; que não havia droga nos demais cômodos da residência; que a abordagem foi no período da tarde; que havia crianças no complexo esportivo no mento da abordagem.

A testemunha Stefani de Oliveira, ouvida como informante, disse, em juízo, que é nora de Ivani; que Ivani havia acabado de chegar do trabalho; que estava sentada dentro de casa; que ouviu gritos de socorro vindo da rua; que saiu para fora do imóvel; que viu Aryel, namorado de Ivani; que policiais estavam agredindo Aryel; que Aryel estava apenas com a chave do portão de casa; que não viu drogas com Aryel; que foi até a delegacia; que foi ouvida pela delegada; que a Dra. Mariflândia, advogada, também estava no local; que nunca viu Ivani usar ou vender drogas; que a depoente estava dentro do imóvel; que saiu para fora do imóvel após ouvir gritos de socorro; que estava dentro do portão; que Aryel estava sendo abordado na calçada em frente da casa; que o Polícia pegou a chave do portão no bolso de Aryel; que os policiais mandaram a depoente e Ivani ficarem na cozinha; que Aryel estava com celular; que não viu dinheiro com Aryel; que Aryel estava sentado na calçada; que a depoente foi algemada pelo policial Guilherme e levada à delegacia; que a depoente foi liberada; que Ivani ficou bem surpresa; que a depoente está sendo processada por tráfico, tendo sido presa dias após os fatos.

A testemunha Geomar Nascimento Lima, ouvida como informante, disse, em juízo, que é irmã de Ivani; que sabe que Ivani está presa porque Aryel foi pego com drogas; que, no dia, passou cedo na casa de Ivani para buscá-la para ir trabalhar; que, no final do dia, a vizinha ligou para a depoente perguntando se sabia que os policiais tinham invadido a residência da irmã; que Ivani tinha acabado de chegar do serviço; que Ivani errou no passado; que Aryel mantinha relacionamento com Ivani; que não conhecia Aryel.

Em seu interrogatório judicial, o réu ARYEL RODRIGUES DE MARES confessou a prática delitiva. Disse que tem 28 anos; que é solteiro; que não tem filhos; que trabalhava até sofrer acidente, em dezembro de 2020; que começou a vender droga depois do acidente que sofreu em dezembro de 2020; que faz uso de "crack" e cocaína; que conheceu Ivani e estava namorando; que residia com Ivani fazia por volta dois meses; que não se recorda há quanto tempo namorava Ivani; que já foi condenado; que estava em regime aberto; que a acusação de tráfico de drogas é verdadeira; que, na data dos fatos, estava na casa de Ivani quando esta estava trabalhando; que pegou um pino de cocaína e deixou frascos no quarto do casal; que saiu de casa; que estava vendendo a droga na avenida; que os policiais viram o interrogado vendendo; que foi

abordado; que, no momento, não tinha droga com o depoente; que vendeu o pino de cocaína para um usuário; que era motoqueiro; que pegou vinte reais com motoqueiro; que o celular do depoente é um Samsung J8; que anda mancando e, por isso, não tentou correr; que a abordagem policial foi na calçada de imóvel que fica ao lado da casa em que reside; que os policiais agrediram o depoente; que gritou socorro; que Ivani ouviu e foi até o portão; que Ivani disse que era namorada do interrogado; que os policiais entraram dentro do imóvel; que Ivani e Stefani ficaram dentro da cozinha; que disse aos policiais que não tinha droga no imóvel; que o interrogado sabia que tinha droga e, por isso, mentiu aos policiais; que Ivani não sabia que tinha droga no local; que os policiais acharam a droga; que a droga estava dentro de dois frascos; que os frascos estavam dentro do quarto de Ivani; que os frascos continham fundo falso, dentro do qual havia droga; que estavam no imóvel Stefani e Ivani; que Stefani é casada com o filho de Ivani; que os celulares apreendidos eram de Ivani e do neto de Ivani; que Ivani não sabia da droga; que não vendia droga na casa; que Ivani tinha trabalhado no dia; que não viu o horário que Ivani chegou em casa; que, durante a abordagem do interrogado, Ivani já estava na casa; que acha que Ivani já foi presa; que conheceu Ivani num bar; que foi agredido pelos policiais quando se recusou a desbloquear o telefone celular; que foi agredido com socos no rosto, perto do olho esquerdo; que viu Ivani quando esta chegou perto do portão do imóvel; que todo o entorpecente encontrado estava dentro dos frascos.

Em seu interrogatório judicial, a ré IVANI NASCIMENTO DOS SANTOS negou a prática delitiva. Disse que tem 43 anos; que é solteira; que não tem filhos menores; que trabalha como diarista e vendia "juju" na residência; que estudou até a terceira série; que é diabética e hipertensa; que já fez uso de todo tipo de droga; que fazia tratamento no CAPS; que foi condenada duas vezes por tráfico; que estava em regime aberto; que mantinha namoro com Aryel; que fazia por volta de um ano que namorava com Aryel; que conheceu Aryel numa festa; que Aryel estava morando com a interrogada fazia três meses; que Aryel já teve envolvimento com o tráfico; que não são verdadeira as acusações; que, no dia, trabalhou e chegou em casa por volta das 16h da tarde; que o portão da residência estava trancado; que deitou no sofá; que ouviu gritos de socorro; que viu que era Aryel; que viu policiais batendo em Aryel; que a interrogada disse que era namorada de Aryel; que a abordagem policial foi ao lado da casa; que os policiais entraram na residência; que fizeram buscas dentro do imóvel; que foi algemada no quarto; que os policiais pediam para a interrogada fazer acordo e entregar toda a droga; que a interrogada não sabia das drogas; que a interrogada ficou na cozinha enquanto os policiais faziam as buscas; que foi chamada dentro do quarto; que não viu os policiais achando a droga; que foram apreendidos dois celulares com a interrogada; que a droga foi localizada no quarto da interrogada; que a interrogada não sabia das drogas dentro de sua casa; que desconhece as fotografias encontradas no celular da interrogada; que estava com o celular há poucos dias; que comprou o celular na semana da prisão de um rapaz chamado Lilson; que pagou R\$ 100,00 (cem reais) pelo aparelho; que não sabia das fotografias no aparelho celular; que não sabe mexer em celular; que, no dia, tinha ido trabalhar na casa de Mari; que Rodrigo é filho da interrogada; que tem uma sobrinha chamada Ingrid; que Aryel foi abordado na calçada da casa da interrogada; que fazia três meses que Aryel residia com a interrogada; que os policiais não advertiram a interrogada acerca do direito ao silêncio.

Em que pese a versão dos réus e o esforço das combativas Defesas durante a instrução probatória e em suas alegações finais, a prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder de Aryel e de Ivani.

Os policiais militares, que haviam recebido denúncias anônimas de que o casal estava praticando tráfico de drogas há alguns dias, visualizaram Aryel, na porta da residência, servir drogas a usuário. Aryel foi abordado e com ele havia três pinos de cocaína, além de uma porção de maconha. O usuário de entorpecentes evadiu-se numa motocicleta. Ivani, que estava dentro da residência, avistou a abordagem policial na porta da residência e correu para dentro do imóvel. Em razão da suspeita de que no imóvel pudesse haver mais drogas, os policiais ingressaram na residência. Presenciaram Ivani, no quarto do casal, com um frasco de spray nas

mãos, o qual tinha fundo fundo falso e dentro dele havia vinte e três porções de cocaína. No quarto também apreenderam outro frasco de spray, semelhante ao que Ivani segurava nas mãos, também com fundo falso dentro do qual havia mais três porções maiores e quatorze menores de substância semelhante ao "crack", além de duas porções de cocaína. A droga apreendida dentro da residência foi encontrada no quarto do casal. Dentro do quarto também havia embalagens plásticas para o acondicionamento de substâncias entorpecentes.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais subsídios de convicção existentes nos autos – especialmente com o laudo de constatação das substâncias entorpecentes – e não há nenhum indicativo a colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatem suas diligências.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338).Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998DJU 02.02.2007, p. 74).

Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas:"(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Ademais, a confissão de Aryel, de que, efetivamente, estava praticando o tráfico de drogas, apresenta destacado valor probante para fins de formação do convencimento judicial. Inicialmente, destaca-se a sua harmonia intrínseca, não apresentando qualquer contradição entre seus próprios termos, sendo absolutamente verossímil. Por outro lado, apresenta harmonia extrínseca, encontrando respaldo em outros elementos de prova coligidos na instrução processual, em especial quando comparada ao laudo de constatação das substâncias entorpecentes e à prova oral colhida em juízo.

No mais, a negativa de Ivani não prospera, pois se encontra isolada do conjunto fático-probatório delineado nos autos. Certo é que, se Ivani não soubesse da guarda da droga e do tráfico de entorpecentes praticado por seu consorte, os tóxicos não seriam apreendidos em frascos que estavam dentro do quarto do casal tampouco haveria embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecente sobre a cômoda

que guarnece o cômodo, devendo-se salientar que Ivani, a qual segurava um dos frascos com droga no momento do flagrante, já tinha chegado do trabalho quando se realizou a abordagem policial de Aryel.

Impende notar, no que concerne ao que se imputa a Ivani, que o celular de sua propriedade foi apreendido e periciado, tendo sido localizadas três imagens contendo balança de precisão pesando quantidades de 140 e 74 gramas de substâncias esbranquiçadas sugestivas para cocaína (fls. 273/274). As imagens foram registradas, em 15/04/2021 e 19/04/2021, no aparelho celular apreendido com Ivani, que mentiu em juízo ao dizer que o celular fora adquirido na semana de sua prisão. Como verifica-se às fls. 261/272, há registro de diversas ligações efetuadas e recebidas, nos meses anteriores, das pessoas de Aryel, seu namorado, de Rodrigo, seu filho, de Stefani, sua nora, e de Ingrid, sua sobrinha. As imagens denotam o particular envolvimento de Ivani com o submundo do tráfico de drogas e mitigam qualquer alegação no sentido de que Ivani não tinha conhecimento do tráfico praticado em sua residência pelo seu amásio. Constata-se, pois, que Ivani tanto tinha conhecimento da existência da droga que se uniu ao convivente para a prática delitiva.

Diante desse cenário, sobretudo levando em consideração as palavras dos policiais, a autoria em relação aos denunciados resta, portanto, de todo comprovada nos autos, uma vez que droga foi efetivamente apreendida em poder de Aryel e de Ivani, restando evidente a ciência e as condutas de trazer consigo e de guardar a droga. E, no caso em apreço, afastam-se as teses defensivas de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo próprio.

Inferir-se do auto de exibição e apreensão e do laudo de constatação provisória acostados aos autos que foram apreendidas em poder dos réus 40,69 gramas de cocaína; 27,19 gramas de cocaína, na forma de "crack", e 7,02 gramas de maconha. Não se trata de quantidade ínfima. Além disso, aliada às demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante, especialmente a forma de acondicionamento da substância e a apreensão conjunta de quantias em dinheiro (R\$ 78,00) e de diversas embalagens plásticas vazias, não é crível a versão de que os acusados são meros usuários. Tais circunstâncias demonstram que as substâncias estavam prontas para o comércio e para tal se destinava.

Por isso, não se mostra cabível acolher a alegação de que todo o entorpecente apreendido destinar-se-ia apenas ao consumo pessoal.

Além disso, o conjunto probatório demonstra, especialmente pelo laudo pericial de fls. 249/252, que o tráfico era praticado nas imediações de locais mencionados no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, atraindo-se, por consectário, a causa de aumento respectiva. A propósito, o flagrante se deu no período da tarde e em dia útil (quinta-feira) e, de acordo com os policiais militares, o complexo esportivo localizado nas adjacências de onde era praticado o tráfico estava sendo frequentado por crianças e adolescentes.

Dessa forma, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como a subsunção dos fatos à figura típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há de se acolher as teses defensivas de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco a de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, presente o elemento subjetivo do tipo, restando evidenciadas as condutas dolosas dos acusados, agindo com a vontade e consciência necessárias.

A conduta típica é antijurídica, não havendo qualquer causa justificante para a realização delas. De acordo com a teoria da ratio cognoscendi, segundo a qual a tipicidade da conduta induz a antijuridicidade, a prova acerca da existência de uma justificativa fica a cargo da defesa, ônus do qual os réus não se desincumbiram. Em termos de culpabilidade, os acusados são imputáveis, já que maiores de 18 anos de idade, além de não se enquadrarem nas situações do artigo 26, caput e parágrafo, do Código Penal; tinham consciência da ilicitude de suas condutas; e lhes era exigível comportamento de acordo com o direito, não tendo sido suscitada qualquer hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.

Dessa feita, estreme de dúvidas que a droga apreendida se destinava ao tráfico, a

condenação dos réus nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.

Cabe salientar, por pertinente, que a agravante inerente à calamidade pública não prospera. Com efeito, em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional decretou, por meio do Decreto Legislativo 06/2020, estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19. Também o fizeram diversos Estados da federação, nos limites de suas competências.

Desde então, passou-se a suscitar o reconhecimento da incidência, em casos ocorridos durante a pandemia de Covid-19, da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, que prevê:

Artigo 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: [...]

II - ter o agente cometido o crime: [...]

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido.

É certo, contudo, que tal reconhecimento indiscriminado da agravante, a par de inadequado sob o ponto de vista dogmático, também enseja, por diversas vezes, gravíssimas injustiças, porquanto, em determinados casos, redundam em punição a maior de pessoas que não apenas não se prevaleceram das fragilidades ensejadas pela pandemia como também foram suas maiores vítimas. Isso posto, vale observar que a finalidade da agravante em questão é, a um só tempo, a de proteger a sociedade (que pode se ver, em contexto de calamidade, desguarnecida dos mecanismos de proteção normalmente existentes) e a de punir mais rigorosamente a conduta daquele que, valendo-se das facilidades decorrentes do contexto calamitoso, pratica delitos. Também nessa esteira prelecionam Celso, Roberto e Fabio Delmanto:

Por ocasião de calamidade pública: O CP manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-o em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc. (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 271).

E assevera Luiz Regis Prado:

Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso revela-se mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Ocorre que, no caso dos autos, o contexto de pandemia não se associa em nada ao cometimento do delito. É dizer, os agentes não se aproveitaram do contexto de pandemia e tampouco altera-se a gravidade do delito em virtude da disseminação ou da contenção do coronavírus, o que não justifica a incidência da agravante. Nesse sentido, confira-se recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES.

AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021) - grifei.

No que diz respeito ao crime de associação para o tráfico, não há comprovação segura de vínculo associativo duradouro e estável entre os réus para a prática, reiterada ou não, de tráfico de drogas, que se reclama para a identificação do delito de associação (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Ao revés, contactou-se apenas a traficância realizada por ocasião da abordagem policial e do flagrante, não havendo informações precisas e detalhadas acerca da atuação anterior e organizada da dupla. Dessa forma, a absolvição é medida que se impõe em relação aos acusados (art. 386, VII, do CPP).

Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, não extrapolou a normalidade do tipo. Em relação aos antecedentes, ambos os réus são reincidentes específicos, o que será valorado na fase subsequente, contudo, Ivani possui outra condenação definitiva hábil a constituir maus antecedentes (Ação Penal nº 0010456-45.2009.8.26.0664, fls. 174/175), impondo a exasperação de sua pena-base. Não há elementos acostados aos autos para permitir a aferição da personalidade dos réus e as suas condutas sociais. O motivo do crime não refoge à normalidade nesse tipo de ilícito. As circunstâncias e as consequências são normais ao tipo penal. Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago, ou seja, não possui sujeito passivo determinado. Passando à análise específica das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a natureza e a quantidade das drogas merecem maior reprovabilidade. Além da diversidade de substâncias - cocaína; cocaína na forma de "crack" e maconha -, o que, por si, denota maior repulsa ao crime, sendo a cocaína e o "crack" extremamente nocivos à saúde humana, a quantidade considerável (40,69 gramas de cocaína, 27,19 gramas de cocaína na forma de "crack"; e 7,02 gramas de maconha) redundaria em dezenas, quiza, centenas de diversas porções das drogas, especialmente de "crack" e cocaína, que seriam redistribuídos a um número indeterminado de usuários finais, destruindo-se desmedidamente a saúde alheia. Desse modo, exaspero a pena-base de Ivani em 1/3 (um terço) para fixá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao passo que acresço a fração de 1/6 (um sexto) à pena-base de Aryel para fixá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço em favor de Aryel a atenuante decorrente da confissão espontânea, pois o réu confessou judicialmente a prática do delito (art. 65, inciso

III, alínea "d", do Código Penal). Por outro lado, milita em desfavor dos réus a agravante da reincidência específica (art. 61, inciso I, do Código Penal), em razão de condenações criminais nos autos nº 000450-88.2018.8.26.0664 (Aryel), com trânsito em julgado em 29/09/2014, e 0012004-32.2014.8.26.0664 (Ivani), com trânsito em julgado em 01/08/2016, com penas ainda não extintas, consoante demonstram os documentos de fls. 173/185 e 185/191. Em relação a Aryel, existindo uma agravante e uma atenuante, sem que haja preponderância entre elas (STJ, HC 597.807/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), nos termos do artigo 67 do Código Penal, promovo a compensação, ficando a pena intermediária mantida no mínimo legal. Em relação a Ivani, agravo em 1/6 (um sexto) a pena intermediária para fixá-la em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, há que se considerar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, consoante exposto na fundamentação. Assim, majoro as penas definitivas na fração mínima, 1/6 (um sexto), o que resulta em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa para Ivani e em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para Aryel. Destaque-se, no que tange ao reconhecimento de causa de diminuição de pena, que o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, prevê que "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". No caso em exame, os réus não têm direito à causa especial de diminuição de pena, porque são reincidentes específicos, de modo que, objetivamente, denota-se a dedicação a atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas, impeditivo legal para a concessão da causa redutora.

À vista do quantum de pena aplicado e da reincidência específica, o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ressalte-se que, embora deva ser considerado para fins de detração, na forma do artigo 42 do Código Penal, o período de prisão preventiva não se mostra suficiente para influenciar na fixação do regime inicial.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica dos réus, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

Conquanto o STF já tenha declarado inconstitucional a proibição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 (quatro) anos e há reincidência em crime doloso, o que impede a sua substituição por medidas restritivas de direitos (artigo 44, I e II, do Código Penal).

Igualmente incabível a suspensão da execução da pena, porquanto superados os dois anos previstos no artigo 77, caput, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), pois o crime é vago, não havendo vítima definida.

Por todas as razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

A) CONDENAR a ré IVANI NASCIMENTO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato;

B) CONDENAR o réu ARYEL RODRIGUES DE MARES pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes fixados em

1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; e

C) ABSOLVER os réus IVANI NASCIMENTO DOS SANTOS e ARYEL RODRIGUES DE MARES da imputação da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista o regime fixado para o início de cumprimento da pena, a reincidência e, ainda, a subsistência dos motivos que outrora fundamentaram o decreto preventivo, MANTENHO a prisão cautelar dos réus, como forma de acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Condene o(a)s sentenciado(a)s também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos diretamente ao Funad.

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

B) coloquem-se os bens e valores perdidos (fls. 34/36) à disposição da União (Funad);

C) expeça-se guia definitiva de cumprimento da pena;

D) intimem-se os réus para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;

E) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

F) lancem-se os nomes dos sentenciados no rol do IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Votuporanga, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA